

1500048-46.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500048-46.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500048-46.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008753/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 15605732 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 5/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2008753 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL FELIPE DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

DANIEL FELIPE DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Antônio Conselheiro, Jardim Ernesto Kuhl, nesta cidade e comarca, o acusado, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo e guardava, para serem entregues ao consumo de terceiros, 14 (quatorze) porções de cocaína, com peso aproximado de 23,3 gramas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão, fotografias e auto de constatação preliminar).

Ao que se apurou, o denunciado trazia consigo e guardava as sobreditas drogas para fins de comercialização.

Ocorre que policiais civis realizavam diligência pelo sítio do evento, conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram o denunciado

transacionando com transeuntes que por ali passavam. Para tanto, após contato com o respectivo transeunte, o denunciado dirigia-se ao canteiro central, pegava algo e, em seguida, entregava àquele.

Realizada a abordagem, com o denunciado foram encontrados 02 (dois) flaconetes contendo cocaína, os quais trazia consigo para fins de narcotráfico, bem como a quantia de R\$70,00 (setenta reais), oriunda da venda ilícita de entorpecentes.

Em seguida, verificado o local onde o denunciado buscava algo, os agentes públicos localizaram 12 (doze) flaconetes de cocaína, idênticos aos que trazia consigo, drogas que guardava para serem entregues ao consumo de terceiros.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 78/79).

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2021 (fls. 80/81).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, sem interrogatório do acusado em razão da revelia (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defensoria Pública ofereceram memoriais orais (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação com resultado positivo para "cocaína" (fls. 23/25 e 53/55), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado admitiu os fatos que ora lhe são imputados, esclarecendo que estava vendendo pinos de cocaína para manutenção de seu próprio vício, uma vez que é viciado em cocaína desde os quatorze anos de idade. Por fim, está arrependido, solicitando internação para tratamento de sua dependência química (fls. 10/11).

Em Juízo, o réu não foi interrogado por ser revel, descumprindo o benefício da liberdade provisória concedido em seu favor (fls. 96/97).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão extrajudicial.

O policial civil Carlos Eduardo de Oliveira Ventura disse que diligenciava com viatura descaracterizada no bairro Ernesto Kuhl, em companhia do investigador Ricardo, quando viu o autuado fazendo contato com um casal em local já conhecido como ponto de venda de drogas, situado na avenida Antônio Conselheiro. Diante disso, o colega Ricardo passou a filmar o réu, que recebeu algo das mãos daquele rapaz. Depois, o acusado atravessou a avenida, indo em direção ao canteiro central, onde pegou algo no chão, entregando-o ao mesmo rapaz que se encontrava em companhia da moça. Posteriormente, o denunciado atravessou a avenida novamente, indo até o canteiro central, onde pegou um pequeno embrulho, que estava embaixo de folhas,

retornando em seguida. Ato contínuo, realizou outra aparente venda de droga aos ocupantes de uma motocicleta, os quais não puderam ser filmados por estarem na frente de um veículo VW/Gol, que se encontrava com o capô aberto, sendo possível, porém, filmar o acusado entregando algo e recebendo dinheiro de um deles. Em vista desses fatos, o depoente e seu parceiro decidiram abordar o denunciado, o qual foi revistado, sendo encontrados dois flaconetes de cocaína em sua cintura, bem como a quantia de R\$70,00 (setenta reais) no bolso de sua bermuda. Em seguida, o investigador Ricardo foi até o canteiro central e, no mesmo lugar onde ele havia buscado as drogas, encontrou mais doze flaconetes idênticos de cocaína. Indagado, o acusado Daniel negou o tráfico sob a alegação de que é apenas usuário, dizendo ainda que o dinheiro que tinha consigo era proveniente da venda de uma bicicleta. O ponto é conhecido nos meios policiais pela traficância (mídia).

O policial civil Ricardo Alfredo Coelho depôs no mesmo sentido. O bairro é conhecido pela traficância. Estava com seu parceiro Ventura quando perceberam o contato do réu com um casal. Passaram a filmar. O acusado Daniel foi até o canteiro central, pegou algo e entregou para o rapaz. Após, ele fez uma possível venda para uma motocicleta, mas antes ele pegou o embrulho no canteiro e entregou para uma motocicleta. Abordado, ele tinha dois porções de cocaína e dinheiro. No canteiro central encontraram doze pinos de cocaína idênticos ao encontrado em seu poder. Indagado, ele negou a traficância. O réu foi por duas vezes no local que encontraram mais drogas. O local da abordagem era próximo do canteiro (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais civis, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10)." (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais civis realizavam diligência pelo local, quando avistaram o réu transacionando com transeuntes que por ali passavam. Isso porque ele se dirigia ao canteiro central, pegava algo e, em seguida, entregava para terceiros.

Diante da suspeita, os policiais abordaram o acusado. Em revista pessoal, foram encontrados 02 (dois) flaconetes contendo cocaína, os quais trazia consigo para fins de venda, bem como a quantia de R\$70,00 (setenta reais), oriunda da venda ilícita de entorpecentes.

Em seguida, em buscas no local onde o réu buscava algo, os policiais civis localizaram mais 12 (doze) flaconetes de cocaína, idênticos aos que trazia consigo, que o réu ali mantinha em depósito para venda ilegal. O acusado foi preso em flagrante delito e na delegacia confirmou a prática do delito.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias e o local da prisão, o depoimento incriminador dos policiais civis e a confissão extrajudicial, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

E não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, assim como das circunstâncias da prisão, com depoimento incriminador dos policiais civis quanto ao tráfico de drogas.

Em conformidade com os ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu:

"Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância. (...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Não foram arroladas testemunhas de defesa que pudessem corroborar a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com o delito de tráfico de drogas, devendo prevalecer o relato dos policiais civis que o prenderam em flagrante delito.

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que o acusado não tinha trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciasse a aquisição de toda aquela quantidade de entorpecente.

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que o acusado tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19. O crime foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)" (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justifica a exasperação da pena-base, pois não se trata de quantidade elevada (14 porções de cocaína, com peso aproximado de 23,3 gramas).

É certo que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. No presente caso, todavia, haveria desproporção no aumento da pena-base, pois a pouca quantidade apreendida reflete elementos ínsitos ao crime, que já prescreve pena mínima em montante elevado (cf. STJ, HC 705.536/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022; AgRg no REsp 1947327/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022; AgRg no HC 700.702/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, sendo o réu primário e de bons antecedentes, não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 1/2 (metade), tornando-se definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir a fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial semiaberto para o caso em questão (apreensão de 14 porções de cocaína, com peso aproximado de 23,3 gramas). Observo que o réu descumpriu o benefício da liberdade provisória, indicando que não é dotado de senso de disciplina, de modo que pena branda dependente de autodisciplina (regime aberto) não é recomendada ao caso, devendo iniciar o cumprimento de pena no regime intermediário.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo que o comportamento do réu, desde a polícia, bem como em juízo (revelia), leva a crer que sua personalidade, no que tange à maturidade e a responsabilidade, torna inviável a conversão da pena em restritivas de direitos, ainda mais porque descumpriu o benefício de liberdade provisória concedido em seu favor.

A benesse não é suficiente e nem eficaz à reprovação de sua conduta, além de não ser socialmente recomendável para a hipótese presente, pois insuficiente à sua ressocialização, já que descumpriu benefício processual.

De fato, a medida alternativa não é suficiente em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do CP (cf. STJ, HC 435.632/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018; HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Com relação ao texto da Lei 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art. 112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

O dinheiro apreendido também restou demonstrado que era proveniente do tráfico, diante das provas carreadas aos autos, motivo pelo qual declaro o seu perdimento em favor da União, que posteriormente será revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº. 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar DANIEL FELIPE DE SOUZA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33 ambos da mesma lei.

Vedo o direito de recurso em liberdade, uma vez que descumpriu o benefício da liberdade provisória (fls. 96/97) e não foi localizado no distrito da culpa no curso do processo, colocando em risco a aplicação da lei penal, o que faço com fundamento no artigo 312 do CPP.

Expeça-se o competente mandado de prisão e a guia de execução provisória, em respeito à Súmula 716 do STF.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA